

1524015-22.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Galizia Noriega

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1524015-22.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524015-22.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELTON DA ROCHA FEITOSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Galizia Noriega

Vistos.

ELTON DA ROCHA FEITOSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso, no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 17h, na esquina da Al. Cleveland, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, com escopo de distribuição a terceiros, drogas, consistentes em 7,6g de maconha e 62,3g de cocaína, substâncias essas entorpecentes e psicotrópicas sob o controle especial da Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 04/05). Auto de exibição e apreensão (fls. 29/30).

Laudo de constatação (fls. 09/11). Laudo de exame químico toxicológico (fls. 200/202).

Folha de antecedentes e certidões - fls. 87/91 e 98/114.

O réu foi notificado (fls. 164).

Apresentada defesa preliminar em favor do réu (fls. 167).
Recebida a denúncia (fls. 169). O réu foi citado (fls. 217).
Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o acusado.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, aduzindo nulidade da prisão feita pela guarda civil. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da reincidência, o direito ao recurso em liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico toxicológico positivo.

A autoria, de igual modo, restou devidamente demonstrada, na medida em que os guardas civis ouvidos em juízo relataram, de forma harmônica, como se deu a abordagem do réu e o encontro das drogas.

Registre-se que a abordagem efetuada pelos guardas civis não é ilegal, pois a própria lei faculta a qualquer do povo a prisão em flagrante, tratando-se, portanto, de ação legítima a dos guardas civis, mormente em se tratando de atitude suspeita do acusado, na cracolândia, desgarrando-se do fluxo, situação típica de quem é traficante e não mero usuário. Não seria razoável impedir a atuação da guarda civil municipal que é justamente a que está presente em maior número na cracolândia.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. (...) III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verificasse que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada (...) (STJ, AgRg no HC 684062/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 03/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 597.923/SP- Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relatr Ministro Nefi Cordeiro - J. em 20.10.2020- DJe 26.10.2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). (STJ-HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).

TRÁFICO - Nulidade da prisão efetuada por Guardas Municipais - Ausência de legitimidade dos Guardas Municipais para realização de busca pessoal - Ilicitude das provas colhidas - Prisão em flagrante que pode ser realizada por qualquer pessoa do povo - Art. 301 do CPP - Nulidade não reconhecida - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -

Depoimentos de guardas municipais - Inexistência de contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Ausência de dúvida que justifica o decreto condenatório - Condenação mantida - Pena-base reduzida ao mínimo legal - Acusado reincidente - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas - Regime inicial fechado justificado pela reincidência - Recurso parcialmente provido (voto nº 41452). (TJSP; Apelação Criminal 1500200-65.2019.8.26.0551; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).

"Ademais, em que pese controvertida a extensão da das atribuições das guardas civis metropolitanas, havendo, inclusive, recurso extraordinário sobre o tema, cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux), extrai-se do art. 301 do CPP que qualquer do povo poderá prender quem quer se encontre nas hipóteses de flagrância do art. 302, e que as autoridades policiais tem o dever de realizar o flagrante. Assim, embora a guarda municipal não se enquadre no conceito de "autoridade policial", inequivocamente tem aptidão para realizar o flagrante facultativo" (Habeas Corpus Criminal nº 2039080-05.2021.8.26.0000 - 7ª Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Reinaldo Cintra - J: 25.3.2021).

Afastada a alegação defensiva de nulidade, passa-se aos depoimentos colhidos em juízo.

Gilmar, GCM, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. O réu veio com um caixote tentando tampar o rosto, demonstrando nervosismo. Ele tentou correr e o parceiro do depoente foi tentar segura-lo. No momento da abordagem encontrou com ele 100 porções de cocaína, 6 de maconha, um martelo e balança de precisão. Eric já tinha sido abordado. Estava com uma moça. Ele foi abordado, identificado, e com ele balança de precisão, faca e ele tinha 26 porções de cocaína e 2 de maconha. A droga estava na coxa direita de Elton, enrolada com plástico de cozinha, filme. Ele tentou entrar para o fluxo, na Praça do cachimbo. Não houve apreensão de dinheiro. O réu falou que ia entrar para o fluxo. Não havia policiais militares ali perto. Só havia viatura da GCM. Cada viatura fica em uma das alamedas e na praça Júlio Prestes. Geralmente ficam policiais por ali. Tem uma base na Praça Coração de Jesus. Na busca pessoal o réu estava com uma caixa de madeira, martelo. A balança de precisão estava na caixa. As drogas na coxa, com plástico filme. Fazem busca pessoal de praxe.

Jilcimar, GCM, reconheceu o réu em juízo e não o conhecia antes dos fatos. Relatou que no dia da abordagem teve o momento do retorno do fluxo e sobe para a rua Helvetia para a limpeza da praça. No deslocamento da Helvetia para a Praça do Cachimbo eles destoava do fluxo e chamou a atenção. Ele tinha um caixote e tampara o rosto. No momento não encontrou nada, ele reagiu, teve que conter para fazer a revista. Ele tinha sacola com martelo, balança, seis porções de maconha 100 de cocaína, tudo em uma sacola preta enrolado na coxa dele, do lado direito e passado com fita. Ele não falou nada após o encontro das drogas. Deu voz de prisão e encaminhou para o segundo DP. A abordagem começou pelo ERIC que estava indo com uma mulher, de mão dada, e visualizaram a viatura e se separaram, o que chamou atenção. Abordou ele e encontrou nas partes íntimas 26 porções de cocaína e duas de maconha, uma balança no bolso e uma faca na cintura. Esperou apoio porque a viatura não tinha guarda preso e foi quando abordaram o réu Elton, pois ele se desgarrou do fluxo. No momento do retorno do fluxo as viaturas se posicionam para evitar tumulto. Eles fazem outro caminho, o que chama a atenção. A viatura do depoente faz cruzamento fixo no local.

Interrogado o réu confessou a prática do delito. "Não trafica". Estava apenas "atravessando" as drogas. Estava passando também com caixotes. É usuário e recebe para passar a droga. Transportava a droga. Ganhava um real por porção de droga. No dia da prisão não se recorda quantas porções. Só quando entrasse lá dentro ia saber quanto ia ganhar. Entregava a droga para um rapaz, esqueceu o nome dele. Não lembra da balança. Estava com martelo e caixotes. Monta barracas também. Já foi processado antes por assalto, um tráfico forjado. Estava em situação de rua e morava na

cracolândia. Por isso tinha o martelo, para montar a barraca. Tem família em São Paulo e não morava com eles porque é um doente, não consegue se livrar do vício do crack e afasta da família. Gostaria de ser internado e não sair mais.

O conjunto probatório é suficiente para a procedência da ação penal.

O réu confessou a prática delitiva e a confissão encontra pleno respaldo na prova oral colhida. Não obstante tenha alegando não traficar, o transporte da droga por ele confessado é figura típica prevista no artigo 33.

Os guardas civis reconheceram o réu e confirmaram que houve encontro das drogas e da balança em poder do réu e ele, por sua vez, confessou que transportava a droga, o que basta para a caracterização do tráfico.

As drogas foram apreendidas e periciadas. A quantidade de droga é absolutamente incompatível com o mero uso, o que, registre-se, nem sequer foi alegado pelo próprio acusado que confessou estar transportando a droga e que ganharia um real por porção transportada.

Assim, considerado o conjunto probatório amalhado, a absolvição do réu é meta impossível de se alcançar, não se tratando de hipótese de reconhecimento de tráfico privilegiado por ser o réu reincidente e portador de maus antecedentes.

Caracterizado o delito de tráfico passo à fixação da pena com fulcro nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Respeitado o sistema trifásico fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, por ser o réu portador de maus antecedentes. Pena-base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase é reconhecida a reincidência. O réu confessou a prática do delito e as circunstâncias se compensam.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, a pena é fixada, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, não sendo o caso de incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pelas razões anteriormente expostas.

A pena pecuniária é fixada, utilizados os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, ante a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de crime grave, assemelhado aos hediondos.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELTON DA ROCHA FEITOSA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu preso a todo o processo, não se justificando a sua soltura após a prolação de sentença condenatória, razão pela qual nego o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, o qual ostenta maus antecedentes e, desta feita, praticou crime grave, assemelhado aos hediondos, a demonstrar que a manutenção da custódia se justifica para a garantia da ordem pública.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Independentemente do trânsito em julgado, já tendo sido apresentado o exame químico toxicológico definitivo, autorizo a incineração da droga, nos termos do art. 32 da Lei nº 11.343/06. Oficie-se.

Deixo de condenar o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, em razão da atuação da Defensoria Pública do Estado.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA